

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 中止未遂が成立するためには、行為者が自己の行為のみで結果発生を防止する必要がある。
2. 既遂犯が成立する場合にも、結果発生防止のための真摯な努力をしていれば、中止未遂が成立する。
3. 窃盗の目的で他人の住居に侵入して物色行為を行った場合、住居に侵入した行為について成立する犯罪と物色行為について成立する犯罪は科刑上一罪の関係に立つので、財物の窃取を自己の意思により中止すれば、いずれの犯罪にも中止未遂が成立する。
4. 予備罪に中止未遂の成立する余地はない。
5. 中止未遂の刑は、刑法第43条ただし書により、任意的に減軽又は免除される。

No138	中止犯	正答率
予備H27-7	正解	78%
	4	

1 誤っている

大判昭12.6.25。判例は、甲がAの住居に放火し、その逃走の際に火勢を見て恐怖を覚えたので、Aの隣人であるBに対し、放火したので「よろしく頼む」と叫びながら走り去ったという事案において、結果発生防止は必ずしも犯人単独で行う必要はないが、結果発生防止行為を他人に依頼する場合には、少なくとも自ら防止に当たったのと同視できる程度の努力を払う必要があるとしている。結果防止努力について、自らの独力で結果を防止した場合のみに限定する必要はないが、結果防止に対する真摯な努力が認められない場合には、中止犯の減免の根拠である責任減少は認められないし、政策的にも一定の結果防止努力をすることが合理的であるからである。

2 誤っている

43条ただし書。同条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減輕することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減輕し、又は免除する。」と規定し、中止未遂が成立するためには、未遂犯の成立が前提となっている。条文が明確に未遂に限定している以上、既遂になった場合に中止未遂が成立するとすることはできない。

3 誤っている

43条ただし書。中止犯が成立する場合、その効果は、中止した犯罪と併合罪の関係に立つ犯罪についてはもちろん、科刑上一罪（観念的競合、牽連犯）の関係に立つ別罪にも及ばないとされている。そして、窃盗の目的で他人の住居に侵入して物色行為を行ったが、財物を奪うには至らなかった場合、住居侵入罪と窃盗未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となり、科刑上一罪となる。よって、住居侵入窃盗の事案において、住居に侵入した上で、財物の物色行為を行ったが、財物の窃取を自己の意思により中止した場合には、窃盗未遂罪については中止犯が成立するが、その効果は、窃盗未遂罪と科刑上一罪の関係に立つ住居侵入罪には及ばない。

4 正しい

最大判昭29.1.20（百選I72事件）。判例は、被告人が、共犯者と相談のうえ、被害者方で強盗をしようと企て、それぞれが出刃包丁等を携えて被害者方に赴いたという事案において、被告人らの行為を強盗予備の共同正犯とした上で、被告人が、自己の罪業の深さに気付き、無意識に一目散に自宅へ帰ったという事情があるとしても、「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものである」として、予備罪における中止未遂の成立を否定している。

5 誤っている

43条ただし書。同条ただし書は、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減輕し、又は免除する」と規定し、中止未遂成立の効果として必要的減免を定め、自己の意思によらない事情により犯罪が完成しなかった障害未遂が任意的減軽であるのとは明確に区別している。よって、中止未遂の刑は、43条ただし書により、必要的に減免される。